

1500417-93.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... denotavam o aliciamento de menores para o tráfico. Não havia outros petrechos referentes a entorpecentes no local.

O adolescente I. contou que conhece o réu de vista, não tem conhecimento do envolvimento dele com o tráfico e nunca comprou nem conversou com o acusado sobre entorpecentes. Afirmou ser a pessoa da fotografia acostada na pg. 20 e disse que não se recordava de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500417-93.2021.8.26.0598

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2329212/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21752956 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6937/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2329212 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEDSON FERNANDO DE OLIVEIRA NARCIZO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

GLEDSON FERNANDO DE OLIVEIRA NARCIZO está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, observada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Notificado (fls. 187), o réu apresentou defesa às fls. 195/198.

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (fls. 206/207) e o acusado foi citado (fls. 244).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 255/256).

Em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a desclassificação da conduta imputada ao réu para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação da pena no patamar mínimo previsto legalmente e o afastamento das agravantes e causas de aumento.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08/18), relatório de informação de fls. 19/24, boletim de ocorrência (fls. 25/28), auto de exibição e apreensão (fls. 29), fotografias (fls. 30 e 32/33), documentos de fls. 60 e 64, laudo de exame químico-toxicológico (fls. 146/152) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu admitiu a propriedade dos entorpecentes encontrados em sua residência, aduzindo que os adquirira em Bariri e que se destinavam ao seu uso. Alegou que em sua casa foram apreendidos dois celulares da marca Motorola, um seu e o outro do seu filho. Negou ter enviado ou recebido as mensagens extraídas pela polícia, pois o seu aparelho era Motorola e o havia comprado do traficante de Bariri na noite anterior aos fatos, então sequer teve tempo de apagar os dados.

O policial civil Felipe narrou que cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do acusado, investigado pelo comércio de entorpecentes com adolescentes, dentre eles W., conhecido como "Bacuri/Baguri". Ao ingressar na casa do réu, encontrou-o dormindo e ao seu lado havia uma bacia com drogas embaladas para venda, além de dinheiro e celular. Na delegacia realizou a extração de dados do telefone do réu e havia conversas dele com "Bacuri" e com o menor I., nas quais o acusado os avisa que possui maconha, inclusive para venda "por peso". Além disso, havia anotações sobre a contabilidade do tráfico e uma delas consignava especificamente a palavra "verde", referindo-se à maconha. Diante das fotografias e do teor das mensagens conseguiu identificar que as pessoas que se comunicavam com o acusado eram os adolescentes W. e I.

O policial civil Evandro relatou que cumpriu mandado de busca na casa do réu e inicialmente fez a varredura no lado de fora. Ao adentrar na sala, outros policiais já tinham encontrado maconha, crack e R\$ 100,00 e um celular em poder do acusado. Ao que soube, as drogas estavam dentro de uma bacia no quarto do réu e foram extraídos dados do telefone dele que denotavam o aliciamento de menores para o tráfico. Não havia outros petrechos referentes a entorpecentes no local.

O adolescente I. contou que conhece o réu de vista, não tem conhecimento do envolvimento dele com o tráfico e nunca comprou nem conversou com o acusado sobre entorpecentes. Afirmou ser a pessoa da fotografia acostada na pg. 20 e disse que não se recordava de ter trocado mensagens com Gledson.

A testemunha de defesa Caíque asseverou conhece o réu há dois anos porque trabalharam juntos. Consumiam entorpecentes, porém o réu nunca comentou sobre vender drogas nem o viu fazendo isso.

A namorada do acusado, Márcia, disse que estavam juntos há um ano e se encontravam diariamente. Certa vez viu alguns objetos na residência do réu e ele lhe confidenciou que era usuário de crack e maconha, mas nunca o viu usando. Não viu movimento anormal de pessoas na casa de Gledson. Tem conhecimento de que o acusado trabalhava fazendo "bicos", malgrado não saiba o que ele fazia, já que não

conversavam sobre isso.

Pois bem.

Gledson admitiu que os entorpecentes lhe pertenciam e sua alegação de que eles eram exclusivamente para seu uso foi rechaçada pelo conjunto probatório amealhado.

O réu era alvo de investigação policial em razão das informações obtidas pela polícia de que ele perpetrava o comércio espúrio e, em cumprimento a mandado de busca expedido em seu desfavor, logrou-se apreender porções de maconha e crack, além de dinheiro e de seu celular.

Do relatório de informações de fls. 19/24, corroborado pela prova oral, verifica-se que as conversas verificadas no celular de Gledson se referem à comercialização de entorpecentes, vez que o réu deixa claro aos interlocutores que tem maconha para venda, inclusive “por peso”.

A alegação do réu de que o celular do qual foram extraídas as mensagens e as anotações contábeis de tráfico não era seu não encontra amparo em qualquer prova. Consta no auto de apreensão (fls. 29) e no boletim de ocorrência de fls. 25/28 que na casa do réu foram apreendidos três celulares, não apenas dois. Ademais, o relato do policial Felipe evidencia que o aparelho estava na posse do acusado quando de sua apreensão.

De outra banda, o encontro de entorpecentes de natureza diversa, a localização de dinheiro sem comprovação de origem lícita, a demonstrada identidade do adolescente I. - que confirmou em juízo ser a pessoa da fotografia de fl. 20 -, aliadas ao teor das mensagens e anotações financeiras, em consonância com as informações iniciais recebidas pela polícia, comprovam que as drogas se destinavam à entrega a terceiros e a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Desta feita, comprovado o cometimento, pelo réu, do crime narrado na denúncia, de rigor a sua condenação.

Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Nesta primeira fase, a pena-base deve ser majorada em vista da alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido - “crack” - substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 172/179 - Processos 0001405-26.2016.8.26.0062, 0002192-89.2015.8.26.0062, 0003081-43.2015.8.26.0062 e 3011536-70.2013.8.26.0302) e a descrita no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”). Considerando que múltipla reincidência do acusado, majoro a reprimenda de 1/3 para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa.

Presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, aumento a

pena de 1/6 para 9 anos e 26 dias de reclusão e 906 dias-multa.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da reincidência.

Tendo em vista que o réu é reincidente e o quantum da pena corporal, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Arbitro o dia-multa em seu valor mínimo, ante a ausência de comprovação de que o réu possa arcar com valor superior.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente

diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu GLEDSON FERNANDO DE OLIVEIRA NARCIZO, qualificado nos autos, à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 906 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, observada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois permaneceu preso no curso do processo e remanescem os requisitos que ensejaram sua custódia cautelar, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos objetos e valores apreendidos com o réu.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA